

1501263-75.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... transação do acusado para realizar tráfico de drogas por meio de ligação telefônica ou pela internet.

Assim, verifica-se que a simples apreensão da droga na carteira do agente não é circunstância indicativa do tráfico de drogas. A rigor, verifica-se que o único elemento que demonstraria o tráfico de drogas seria a confissão extrajudicial, que culminou por não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501263-75.2021.8.26.0545

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315938/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 21497691 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2315938 - DEL.POL.NAZARE PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de Kadson Reinaldo Lima da Silva, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06).

Narra-se na denúncia, em resumo, que “no dia 20 de novembro de 2021, por volta de 00h00, na Rua São Paulo, 441, Mascate, na cidade e comarca de Nazaré Paulista/SP, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 30 (cinquenta) porções individualizadas de cocaína, acondicionadas em papelotes e pesando cerca de 32 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (fls. 2/3).

A denúncia foi recebida em 16/02/2022.

Promovida a citação (fls. número), Kadson Reinaldo Lima da Silva apresentou resposta à acusação (fls. 188/197).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 30/33), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. Constam dos autos, ainda, os seguintes elementos probatórios: Auto de Constatação Preliminar (fl. 27), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 28/29), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 245-247).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Rafael Gomes de Lima (policial militar) relatou que reconhece o acusado; que na data dos fatos realizava patrulhamento junto ao soldado Pires quando no bar da Marluce, com várias denúncias de tráfico de entorpecentes, em que um dos denunciados seriam Kadson e José Ricardo, visualizaram os dois consumindo cocaína no degrau próximo à rua; que os abordaram, primeiro o José Ricardo, e com ele não havia nada de ilícito, mas ele confessou que consumia cocaína com Kadson; que também estariam tomando vinho; que logo em seguida revistaram Kadson e Pires localizou uma sacolinha pequena com umv oluem dentro e de imediato Kadson dizia ser papel higiênico usado, por estar gripado, com a intençã ode não abrir; que abriu e achou trinta invólucros de cocaína e quantia de R\$ 127,00; que, em seguida, deram voz de prisão; que isso foi próximo a meia noite, o bar já fechado e os dois sentados na rua; que há denúncia de quatro ou cinco indivíduos que traficariam no local, mas no dia só os dois foram localizados; que, em data posterior, José Ricardo foi preso no mesmo local; que quanto ao dinheiro ele alegou que era dele, mas não falou de onde veio; que já tinha o abordado anteriormente, mas nada de ilícito fora encontrado; que é conhecido dos meios policiais; que deram dicas, ele é de uma boa família, não precisava disso; que os dois já foram presos por tráfico; que os dois estavam consumindo cocaína; que a droga foi encontrada no bolso da frente, com encaixe para as duas mãos.

A testemunha Alexsander Poscai Pires relatou que na data estava com o cabo Rafael em patrulhamento no bairro Mascate pela rua principal, conhecida pela venda de

entorpecente; que em frente ao bar da Marluce avistaram os dois indivíduos e quando se aproximaram viram ser Kadson e José Ricardo; que, em abordagem em José Ricardo nada encontrou; que, em abordagem em Kadson, encontraram uma sacola que não sabiam o que era; que Kadson disse que era papel higiênico usado porque estava gripado; que acompanharam Pires abrindo e constataram que era entorpecente; que eram trinta papeoplotos de cocaína e R\$ 127,00; que na escada encontraram papelotes abertos que estavam consumindo naquele momento, mais bebida alcoólica; que já o abordou diversas vezes, em diversos horários, mas na parte noturna era fácil encontrá-lo, a partir das 20h ele já estava na rua, mas também já houve diversas diurnas; que se lembra da blusa, com um bolso frontal, não se lembra a cor; que eles ficam vendendo até às 23h mas no dia eles passaram um pouco, acha que por estarem bebendo.

O informante José Ricardo Ribeiro dos Santos relatou que já tinha comprado um papelote na boca; que tinha dez reais; que desceu de casa e encontrou Kadson; que voltou, pegou mais R\$ 150 e Kadson também tinha um dinheiro; que compraram quinze papelotes cada, sentaram na escada; que o bar não é ponto de tráfico; que estavam consumindo, já dois papelotes abertos, e bebendo vinho, quando foram abordados; que não havia mais ninguém no local; que o ponto de droga fica alguns metros a frente; que só se vende droga até as 22h, só até esse horário que o crime fica lá; que faz tratamento de abstinência; que a droga estava na escada no canto e os policiais falaram que a droga era dele; que a droga ficou toda com Kadson; que Kadson tinha mais dinheiro com ele.

O acusado Kadson Reginaldo Lima da Silva relatou que estava perto de casa, desceu para o bar, começou a beber, mora no Mascate grande; que nessa já desceu, foi para a biqueira, comprou pó com Ricardo; que já tinham gastado dinheiro um Velho Barreiro e dois litros de vinho; que compraram trinta pós e dois de brinde; que o traficante não os deixou cheirar ali; que abriu dois papelotes e fizeram quatro carreiras para cheirar; que foram abordados enquanto cheiravam; que acharam a sacolinha de droga; que o policial o repreendeu; que não estava vendendo droga; que Rafael sabe quem é os traficantes, pois mora do lado da biqueira; que trabalha como caseiro; que ganhou R\$ 300 na sexta-feira; que no dia da abordagem tinha R\$ 127 na sua carteira; que não falou nada na delegacia porque estava sob efeito da droga; que está fazendo tratamento no presídio.

Quanto à tipificação, é cediço que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) consiste em tipo misto alternativo com 18 (dezoito) núcleos do tipo e sem elementos subjetivos especiais, ao passo que o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte de droga para uso pessoal) consiste também em tipo misto alternativo com 5 (cinco) núcleos do tipo, todos eles também constantes do art. 33, mas com a distinção de um elemento subjetivo especial: a destinação do objeto material do crime (droga) ao consumo pessoal.

Diante de tais figuras típicas similares, distintas sobretudo pela destinação da droga, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 estabelece os critérios que devem ser considerados pelo órgão julgador para estabelecer se a droga tinha destinação ao consumo pessoal: (i) a natureza e a quantidade da substância apreendida (circunstâncias objetivas), (ii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação (circunstâncias espaciais), (iii) as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (circunstâncias subjetivas).

Assim, à luz do princípio da presunção de inocência e da regra probatória que dele decorre, é forçoso reconhecer que a subsunção do fato ao tipo penal mais gravoso (art. 33) depende do afastamento, para além de dúvida razoável, da destinação da droga ao uso pessoal (art. 28), mediante verificação dos critérios legais constantes do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06. Do contrário, na situação de dúvida, deve esta ser resolvida em favor do acusado, com a subsunção ao tipo penal menos gravoso, consectário dos princípios do in dubio pro reo e do favor rei. Nesse sentido, vale conferir a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no

juízo do REsp 1.769.822/PA (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2018).

Uma vez firmadas tais premissas, no caso ora em apreço, após o término da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que não ficou comprovada a destinação da droga à comercialização (tráfico). Ao revés, remanesce dúvida razoável quanto à destinação das drogas à comercialização ou ao consumo pessoal (uso próprio), razão pela qual se impõe a desclassificação da imputação constante da denúncia, de tráfico de drogas, para a infração penal de porte de drogas para uso pessoal.

Com efeito, a despeito das substanciosas razões apresentadas pelo Ministério Público, no caso a natureza (uma espécie apenas: cocaína) e a pequena quantidade (24,5g – fls. 246) da droga (circunstâncias objetivas) mostram-se compatíveis com a destinação ao consumo pessoal.

O local e as condições da ação (circunstâncias espaciais), de igual modo, não são suficientes para comprovar a traficância em elevadíssimo grau de probabilidade, embora tampouco se possa descartá-la. Com efeito, verifica-se que, embora a polícia tenha narrado que havia denúncias anônimas de tráfico de drogas e que houve diligências que confirmaram o seu teor, não juntadas tais denúncias aos autos nem foram feitas filmagens ou fotografias dos atos de traficância que teriam sido realizadas no local da abordagem. Ambos os policiais relataram que ambos os abordados estavam consumindo as drogas em via pública quando foram surpreendidos. Os policiais ressaltaram ainda que não havia mais ninguém no local àquele momento e que usualmente o tráfico de drogas no local só ocorre até as 23h, mas a abordagem foi feita posteriormente. Assim, a despeito do vacilante depoimento do informante José Ricardo, é certo que no caso a prova produzida é insuficiente para a condenação à luz do standard probatório

Nesse cenário, verifica-se que todo o acervo probatório deste caso se concentra à apreensão de droga de uma espécie, em pequena quantidade, acompanhada de dinheiro de origem desconhecida. Não foram flagrados atos de comercialização. Não foram localizados petrechos para comercialização, tais como balança de precisão ou mesmo sacolas ou embalagens para acondicionamento, tampouco vestígios da comercialização, tais como anotações, contabilidade. Não houve tentativa de interceptação telefônica ou quebra de sigilo de dados telemáticos para verificar eventual comunicação ou transação do acusado para realizar tráfico de drogas por meio de ligação telefônica ou pela internet.

Assim, verifica-se que a simples apreensão da droga em poder de agente que inclusive estava consumindo a droga em via pública não é circunstância indicativa do tráfico de drogas.

Por fim, quanto aos antecedentes do agente, trata-se de elemento que, isolado, não se presta a amparar a condenação.

Logo, à luz do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, mostra-se imperativa a desclassificação do crime, a fim de que seja afirmada a subsunção do fato ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e não no art. 33 do mesmo diploma legal.

Com efeito, vale ressaltar que, no processo penal, o standard probatório necessário para a condenação é de altíssima probabilidade, sintetizado no brocardo anglossaxão “para além de dúvida razoável” (beyond any reasonable doubt – BARD).

Uma vez operada a desclassificação supra, constata-se que o acusado, de forma consciente e voluntária (dolo direto), praticou a conduta de guardar consigo droga para consumo pessoal, fato típico, ilícito e culpável, em razão do qual devem ser a

ele aplicadas as sanções previstas no preceito secundário do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à pena aplicável, é forçoso reconhecer que, no curso da persecução penal, foi decretada a prisão provisória do acusado, a qual perdurou até a sua revogação por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As sanções penais aplicáveis ao crime praticado pelo acusado (art. 28 da Lei n. 11.343/06), por sua vez, são simplesmente penas restritivas de direito, tendo em vista ser inaplicável ao referido crime qualquer modalidade de pena privativa de liberdade (“despenalização”, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da QO no RE 430.105).

Quanto à tipificação, é cediço que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) consiste em tipo misto alternativo com 18 (dezoito) núcleos do tipo e sem elementos subjetivos especiais, ao passo que o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte de droga para uso pessoal) consiste também em tipo misto alternativo com 5 (cinco) núcleos do tipo, todos eles também constantes do art. 33, mas com a distinção de um elemento subjetivo especial: a destinação do objeto material do crime (droga) ao consumo pessoal.

Diante de tais figuras típicas similares, distintas sobretudo pela destinação da droga, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 estabelece os critérios que devem ser considerados pelo órgão julgador para estabelecer se a droga tinha destinação ao consumo pessoal: (i) a natureza e a quantidade da substância apreendida (circunstâncias objetivas), (ii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação (circunstâncias espaciais), (iii) as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (circunstâncias subjetivas).

Assim, à luz do princípio da presunção de inocência e da regra probatória que dele decorre, é forçoso reconhecer que a subsunção do fato ao tipo penal mais gravoso (art. 33) depende do afastamento, para além de dúvida razoável, da destinação da droga ao uso pessoal (art. 28), mediante verificação dos critérios legais constantes do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06. Do contrário, na situação de dúvida, deve esta ser resolvida em favor do acusado, com a subsunção ao tipo penal menos gravoso, consectário dos princípios do in dubio pro reo e do favor rei. Nesse sentido, vale conferir a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.769.822/PA (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2018).

Uma vez firmadas tais premissas, no caso ora em apreço, após o término da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que não ficou comprovada a destinação da droga à comercialização (tráfico). Ao revés, remanesce dúvida razoável quanto à destinação das drogas à comercialização ou ao consumo pessoal (uso próprio), razão pela qual se impõe a desclassificação da imputação constante da denúncia, de tráfico de drogas, para a infração penal de porte de drogas para uso pessoal.

Com efeito, a natureza (uma espécie apenas: cocaína) e a quantidade 11g – onze gramas) da droga (circunstâncias objetivas) mostram-se compatíveis com a destinação ao consumo pessoal.

O local e as condições da ação (circunstâncias espaciais), de igual modo, em nada indicam a traficância. Com efeito, verifica-se que, embora a polícia tenha narrado que havia denúncias anônimas de tráfico de drogas e que houve diligências que confirmaram o seu teor, não foram feitas filmagens ou fotografias dos atos de traficância que teriam sido realizadas em praça pública. O próprio policial Eduardo Sandro de Godoi, em juízo, relatou que não visualizou troca de objetos entre o acusado e terceiros, mas apenas conversas, o que é pouco para configurar o crime de tráfico de drogas. A saber, não houve a identificação de nenhuma conduta típica de

comercialização ou distribuição da droga e sem a identificação de qualquer terceiro potencial comprador ou usuário da droga. Quanto ao resultado da diligência de busca domiciliar, verifica-se que, na verdade, a diligência foi praticamente infrutífera: a apreensão foi de apenas dez papелotes de cocaína na carteira do agente, em busca pessoal. Nenhuma droga a mais foi localizada em toda a residência apesar da busca realizada com base no mandado expedido. Não foram localizados petrechos para comercialização, tais como balança de precisão ou mesmo sacolas ou embalagens para acondicionamento, tampouco vestígios da comercialização, tais como anotações, contabilidade. Não houve tentativa de interceptação telefônica ou quebra de sigilo de dados telemáticos para verificar eventual comunicação ou transação do acusado para realizar tráfico de drogas por meio de ligação telefônica ou pela internet.

Assim, verifica-se que a simples apreensão da droga na carteira do agente não é circunstância indicativa do tráfico de drogas. A rigor, verifica-se que o único elemento que demonstraria o tráfico de drogas seria a confissão extrajudicial, que culminou por não ser corroborada em juízo, de modo que não pode, isoladamente, amparar a condenação. A defesa carреou aos autos laudos médicos que demonstram que o réu é acometido de doença que acomete a sua integridade psíquica e o réu, em juízo, ressaltou que só confessou o crime em juízo por ter medo da polícia. Em tal cenário, a confissão extrajudicial, não confirmada em juízo, não pode ser por si só elemento suficiente para amparar a condenação.

Deveras, vale ressaltar que, no processo penal, o standard probatório necessário para a condenação é de altíssima probabilidade, sintetizado no brocardo anglossaxão "para além de dúvida razoável" (beyond any reasonable doubt - BARD).

Por fim, quanto aos antecedentes do agente, trata-se de acusado primário e não há outras circunstâncias subjetivas que possam ser considerados indicativos da destinação da droga ao tráfico.

Logo, à luz do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, mostra-se imperativa a desclassificação do crime, a fim de que seja afirmada a subsunção do fato ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e não no art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim, uma vez operada a desclassificação supra, constata-se que o acusado praticou conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que estão preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime.

Uma vez operada a desclassificação, é forçoso reconhecer que, no curso da persecução penal, foi decretada a prisão provisória do acusado, a qual perdurou até a sua revogação por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As sanções penais aplicáveis ao crime praticado pelo acusado (art. 28 da Lei n. 11.343/06), por sua vez, são simplesmente penas restritivas de direito, tendo em vista ser inaplicável ao referido crime qualquer modalidade de pena privativa de liberdade ("despenalização", consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da QO no RE 430.105).

Em tal cenário, à luz do que ordena o art. 42 do Código Penal (cômputo do tempo de prisão provisória como cumprimento de pena: detração), o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconheceu o prévio exaurimento da pretensão punitiva e a falta de interesse na aplicação da pena em razão do cumprimento de prisão provisória de natureza mais gravosa que a própria pena aplicável ao crime, de modo a justificar a declaração da extinção de punibilidade.

A saber, tal corte de superposição reconhece a incidência da assim denominada "detração penal analógica virtual" em tais situações em que a prisão cautelar cumprida no curso do processo mostra-se por si só mais gravosa do que a pena abstratamente aplicada ao crime ao final reconhecido como praticado. Nesse sentido,

confirmam-se: STJ, REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, e STJ, HC 390.038/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/02/2018.

No caso ora em apreço, o acusado ficou acautelado em regime fechado e o crime reconhecido como praticado nem sequer é sancionado com pena privativa de liberdade, o que torna tal prisão desproporcional e revela que a pretensão punitiva estatal se esgota em tal prisão cautelar e assim inviabiliza a prolação de uma condenação.

A extinção da punibilidade, na hipótese, funda-se na verificação do prévio exaurimento da pretensão punitiva do Estado em razão do reconhecimento da coerção cautelar desproporcional no curso do processo, e não em razão do esgotamento de processo executivo pelo cumprimento de pena, nem sequer deflagrada.

Por tais razões, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a sentença de reconhecimento da extinção de punibilidade por exaurimento da pretensão punitiva tem natureza declaratória e não condenatória, de modo a não gerar reincidência nem outros efeitos penais ou extrapenais da condenação (STJ, HC 390.038/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/02/2018). Ademais, mesmo que assim não fosse, ressalte-se que a condenação pela prática do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 não é fato gerador de reincidência, nem de Maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 520.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/10/2019; STJ, REsp 1.672.654/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/08/2018).

Por tais razões, deve ser aplicada a detração penal analógica virtual e reconhecida a extinção de punibilidade pelo prévio exaurimento da pretensão punitiva pela aplicação de prisão preventiva desproporcional à gravidade da infração penal verificada.

Ante o exposto, tendo em vista a desclassificação da infração para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a prisão preventiva do acusado no curso do processo, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com supedâneo no artigo 42 do CP.

Promova-se a restituição do valor apreendido ao acusado, observado o art. 123 do CPP e o art. 516 das NSCGJ.

Sem custas (CPP, art. 804).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica e o acusado.

Em tal cenário, à luz do que ordena o art. 42 do Código Penal (cômputo do tempo de prisão provisória como cumprimento de pena: detração), o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconheceu o prévio exaurimento da pretensão punitiva e a falta de interesse na aplicação da pena em razão do cumprimento de prisão provisória de natureza mais gravosa que a própria pena aplicável ao crime, de modo a justificar a declaração da extinção de punibilidade.

A saber, tal corte de superposição reconhece a incidência da assim denominada “detração penal analógica virtual” em tais situações em que a prisão cautelar cumprida no curso do processo mostra-se por si só mais gravosa do que a pena abstratamente aplicada ao crime ao final reconhecido como praticado. Nesse sentido, confirmam-se: STJ, REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, e STJ, HC 390.038/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/02/2018.

No caso ora em apreço, o acusado ficou acautelado em regime fechado e o crime

reconhecido como praticado nem sequer é sancionado com pena privativa de liberdade, o que torna tal prisão desproporcional e revela que a pretensão punitiva estatal se esgota em tal prisão cautelar e assim inviabiliza a prolação de uma condenação.

A extinção da punibilidade, na hipótese, funda-se na verificação do prévio exaurimento da pretensão punitiva do Estado em razão do reconhecimento da coerção cautelar desproporcional no curso do processo, e não em razão do esgotamento de processo executivo pelo cumprimento de pena, nem sequer deflagrada.

Por tais razões, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a sentença de reconhecimento da extinção de punibilidade por exaurimento da pretensão punitiva tem natureza declaratória e não condenatória, de modo a não gerar reincidência nem outros efeitos penais ou extrapenais da condenação (STJ, HC 390.038/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/02/2018). Ademais, mesmo que assim não fosse, ressalte-se que a condenação pela prática do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 não é fato gerador de reincidência, nem de maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 520.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/10/2019; STJ, REsp 1.672.654/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/08/2018).

Por tais razões, deve ser aplicada a detração penal analógica virtual e reconhecida a extinção de punibilidade pelo prévio exaurimento da pretensão punitiva pela aplicação de prisão preventiva desproporcional à gravidade da infração penal verificada.

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia a fim de CONDENAR o acusado Kadson Reginaldo Lima da Silva pela prática do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11/340/06.

Sucessivamente, tendo em vista a prisão preventiva do acusado no curso do processo, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com supedâneo no artigo 42 do CP (detração analógica virtual).

Consequentemente, revoga-se a prisão preventiva anteriormente decretada.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, imediatamente.

Promova-se a restituição do valor apreendido ao acusado, observado o art. 123 do CPP e o art. 516 das NSCGJ.

Sem custas (CPP, art. 804).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica e o acusado.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Nazaré Paulista, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA